

1523141-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/04/2022

... à venda das camisetas e não do tráfico). Nenhum dos agentes visualizou o réu comercializando estupefacientes. Feita a varredura no local, não encontraram outras substâncias. Segundo o PM Michel, não é correto afirmar categoricamente tratar-se de ponto de tráfico o local da prisão (foi a primeira vez que prendeu alguém ali). Corroborando a afirmação de que o acusado tinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1523141-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260573/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 20440170 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4310/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2260573 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DANILO DE MELO NERI

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

13/04/2022

Aos 17 de abril de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). MAURÍCIO LLAGOSTERA MARCHESE RODRIGUES, o(a) Dr(a). VERA MARIA DA CRUZ - OAB 189114/SP, Defensor(a) do ré(u) solto JOSE DANILO DE MELO NERI (presente), os Policiais Militares ENEIAS DOS REIS SANTANA e MICHEL SILVA DOS SANTOS . Instalada a audiência foram ouvidas 02 testemunhas de acusação, a saber, ENEIAS DOS REIS SANTANA e MICHEL SILVA DOS SANTOS (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. A Defesa desistiu da oitiva da(s) testemunha(s) faltante(s), o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após conversar com sua Defesa, o(a) ré(u) foi interrogado(a) pelo sistema de áudio e

vídeo. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. O(a) Dr(a) Promotor(a) se manifestou em sede de debates orais através do sistema de gravação de áudio e vídeo. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), em debates orais, foi dito que: "MM Juiz: Segundo a denúncia do Ministério Público, o denunciado encontra-se incurso nas sanções do crime prescrito no art. 33 da lei nº 11.343/06, " Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 11h06m, na Rua Francisco Alvares Correia, altura do numeral 194, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo, JOSE DANILO DE MELO NERI, qualificado à fl. 05, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 09 frascos plásticos contendo maconha (5,3g), substância entorpecente, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, segundo consta no boletim de ocorrência de fls. 06/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11 e no laudo de constatação de fls. 14/16". Ocorre que, o denunciado é apenas um usuário de drogas que estava no local, pois é próximo da sua residência. Com o denunciado nada foi encontrado, uma vez que toda a droga foi encontrada em local inacessível para o denunciado. Durante audiência de instrução realizada por este Douto Magistrado, através dos depoimentos dos policiais, foi confirmado que a droga fora encontrada na rua, não sendo possível afirmar se a droga era ou não do denunciado. Verifica-se que não há nenhuma prova capaz de imputar ao denunciado a prática do crime constante na denúncia. Em síntese, são os fatos. MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO Conforme informações dos autos percebe-se a ausência de qualquer prova que o denunciado tinha a intenção de vender a droga apreendida no local do crime. Em seu interrogatório, o denunciado é categórico ao afirmar que é apenas usuário habitual e jamais se envolveu na mercancia de qualquer entorpecente. Diante da insuficiência das provas, não há como imputar ao denunciado a autoria pela prática de tráfico de drogas, de forma que, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, o juiz deverá absolvê-lo. As provas trazidas aos autos claramente ratificam o envolvimento do denunciado somente como usuário, estando provado que este não concorreu de forma alguma para a prática do crime constante na denúncia. Caso não seja este o entendimento do MM. Juízo, torna-se incontestável então a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro réu, uma vez que certa é a dúvida acerca da culpa a ele atribuída com relação à acusação de Tráfico de Drogas, pois o Réu não foi encontrado em atividade de traficância e muito menos com qualquer outro elemento que levasse a crer ser o denunciado traficante. Veja Exa., que, com o acusado nada de ilícito foi encontrado e o local onde foi detido fica próximo de sua residência. Destarte, diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram para que pudessem imputar a prática delituosa ao denunciado, não conseguindo, consequentemente, demonstrar que fora a conduta do denunciado que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que ressaí dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente. Nesse sentido, temos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VI, DO CPP. A condenação do réu exige prova robusta da autoria do fato delituoso que lhe é imputado. Remanescendo dúvida, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. Sendo assim, o denunciado deve ser ABSOLVIDO, com fundamento no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, por não haver qualquer prova de que o Sr. Jose Danilo, tenha concorrido para o tráfico de drogas. Se este não for o entendimento, que seja ABSOLVIDO nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devida inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação pela figura do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO Em seu interrogatório, o denunciado explica o motivo de estar no local onde foi preso. Trata-se de um usuário, que estava em local "destinado para usuários", fato este de conhecimento da polícia. Numa simples análise do art. 28 e do art. 33 da lei nº 11.343/06 é notório que a vontade do agente e a destinação

para uso pessoal do denunciado, o simples indício de materialidade do crime de tráfico de drogas não é argumento suficiente para a condenação pelo delito do art. 33 da referida lei. Para iniciar a ação penal bastam indícios mas, para condenar é necessária prova. Com ele nada foi encontrado, estando apenas no local onde foi encontrado as drogas que fica de frente de sua residência, fato este comprovado pelo próprio Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial e confirmado em audiência. Além do mais, trata-se de um réu primário e com residência fixa, a sua primariedade é sim uma coisa que deve ser observada, pois o denunciado não ostenta a atividade criminosa. Conforme se observa do exposto, resta por comprovada a situação do denunciado como usuário de drogas, conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, e não a de traficante, conforme aduzido na denúncia. Não há prova nos autos que, de acordo com a análise dos depoimentos, do local do fato, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do Réu, cheguem à certeza plena de que a prática do fato era realmente tráfico de drogas, razão que demonstra caso típico de desclassificação. Do exposto, caso Vossa Excelência não vislumbre a ideia da absolvição, requer que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06. DOS POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA Embora nítida a tese da absolvição por não estar comprovado o crime de tráfico, e ainda, a tese da desclassificação necessária para usuário, convém demonstrar outras situações que devem ser observadas por Vossa Excelência. Verificando a situação do denunciado, é possível concluir que o réu é primário e de bons antecedentes e possui residência fixa. Nesse sentido entende o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A DOIS ANOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SURSIS. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, sessão de julgamento de 1º.9.2010, Informativo/STF 598). (...) 5. Concessão de ofício para reconhecer a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao Paciente por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, devendo a análise ser feita pelo juízo do processo de conhecimento ou, se tiver ocorrido o trânsito em julgado, pelo juízo da execução da pena. Ainda no que tange ao entendimento do STF: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...) Assim, ao denunciado deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme garantida pela lei penal; e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas.

DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE Na busca do caráter ressocializador da pena, a justiça deve trabalhar para aplicar aquilo que se coaduna com a realidade social. Hoje, infelizmente, nosso Sistema Prisional é cercado de incertezas sobre a verdadeira função de ressocialização dos indivíduos que lá são mantidos, onde em

muitos casos trata-se de verdadeira “escola do crime”. Com base no princípio da presunção de inocência, previsto na nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LVII, requer o denunciado que responda ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, pois as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis pelo fato de não haver reincidência e sua conduta social não ser em nenhum momento questionada. DO PEDIDO Pelo exposto, requer Vossa Excelência digne-se de: 1. Absolver o denunciado Jose Danilo, pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP. 2. Caso não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. 3. Pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o denunciado é usuário de drogas. Por necessário, ad argumentum, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, sejam observadas as atenuantes da: a) menoridade penal, art.65, I, do CP; b) preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de drogas; c) causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: “Vistos. JOSÉ DANILO DE MELO NERI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, em 23 de setembro de 2021, por volta das 11h06min, na Rua Francisco Alvares Correia, altura do numeral 194, Itaim Paulista, nesta Capital de São Paulo, teria trazido consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 09 (nove) frascos plásticos contendo maconha (5,3g), substância entorpecente, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A denúncia foi recebida (fls. 114/115), seguindo-se a apresentação de resposta à acusação (fls. 107/113). O feito prossegue, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (fls. 116). Na audiência designada para o dia 13 de abril de 2022, foram ouvida 02 (duas) testemunhas, interrogando-se o réu na sequência. Encerrada a instrução, o Ministério Público e a defesa postularam a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Relatei sumariamente. Fundamento e DECIDO. A materialidade delitiva encontra-se parcialmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fl. 14), laudo pericial (fls. 17/19 e 144/146), como pelos depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório. Igualmente comprovada a autoria, haja vista a confissão parcial do réu em Juízo, o qual, embora tenha negado o tráfico, consentiu ter adquirido a droga para consumo pessoal. JOSÉ afirmou que, na data dos fatos, saiu de manhã objetivando cobrar seus clientes pela venda de camisetas (as quais foram compradas no Centro de São Paulo, para revenda). Passou por momentos difíceis, e por isso adquiriu a maconha para uso próprio. Pagou R\$ 10,00 (dez reais) pela porção. No dia, fez uso de droga, pouco antes de ser preso. Hoje em dia não faz mais. Tem 23 anos. Nunca havia sido preso. Nem adolescente. Sempre foi trabalhador. Os policiais militares Eneias dos Reis Santana e Michel Silva dos Santos confirmaram a versão do acusado, cujo discurso se manteve coerente desde quando abordado (o dinheiro apreendido referia-se à venda das camisetas e não do tráfico). Nenhum dos agentes visualizou o réu comercializando estupefacientes. Feita a varredura no local, não encontraram outras substâncias. Segundo o PM Michel, não é correto afirmar categoricamente tratar-se de ponto de tráfico o local da prisão (foi a primeira vez que prendeu alguém ali). Corroborando a afirmação de que o acusado tinha feito uso da maconha naquele dia, esse policial esclareceu que o réu parecia estar sob efeito de álcool, um tanto confuso. Dissera-lhe que passava por momento difícil na casa dele e estava meio perdido na vida. Já o encontrou em situação anterior. Estava com outro policial. Em patrulhamento, naquel'outro dia, JOSÉ teve algum surto psicótico. Jogou-se no chão. Não houve abordagem, apenas de passagem a viatura. Absolutamente apropriadas as razões apresentadas pelo Parquet em suas alegações finais apresentadas oralmente, às quais me reporto como razão de decidir.

É a hipótese, efetivamente, de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, a averiguação, em cada caso concreto, do elemento subjetivo do tipo deve ser feito nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, verbis: 'Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. A quantidade (nove porções de maconha) é compatível com uso próprio. O local onde se dera a prisão não é ponto de tráfico, segundo o PM Michel. A diligência policial (condições) foi duvidosa, consoante retratado pelos milicianos. Quanto às circunstâncias sociais e pessoais, o réu afirmou trabalhar com a venda de camisetas. A conduta de JOSÉ também lhe favorece. Desde a abordagem apresentou o mesmo discurso. Finalmente, é de ser dado destaque, no critério dos antecedentes, o certificado à fl. 30: nada há que desabone o acusado. Por isso, acolho o pleito subsidiário formulado pela i. Defesa de molde a desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Resta apenas apreciar a reprimenda adequada. Nos autos da Apelação nº 0001190-25.2010.8.26.039, rel. Des. Souza Nucci, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou ao caso o princípio da detração penal. Reproduzo as lições trazidas em referido aresto, porquanto inteiramente aplicáveis ao caso em testilha, já que JOSÉ permaneceu preso por 1 (um) dia [23/09/2021 (fls. 04 e 91)]: 'Tendo em vista o efeito devolutivo da apelação, desclassificado a conduta delitiva para o porte de droga para consumo próprio, o qual, consoante preceito secundário do artigo 28, da Lei 11.343/06, não prevê a pena privativa de liberdade. Irrazoável é a imposição de qualquer espécie de pena, nesse momento, porquanto encarcerado o apelante ficou, em tese, indevidamente. Solução, nesses casos, é a aplicação do mesmo entendimento da detração na pena de multa. Dessa forma, vimos entendendo: 'Detração e pena de multa: aplica-se, por analogia, no desconto da pena de multa o tempo de prisão provisória. Assim, quem foi preso preventivamente para, ao final, ser condenado apenas à pena pecuniária não terá nada a cumprir'. Destarte, em consonância com a coerência do sistema, justo se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade, em favor do apelante'. É o que, aqui também, fica decidido. CONCLUSÃO. Ante o exposto, desclassifico a conduta investigada para o delito constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, bem como, por meio da detração, declaro extinta a punibilidade de JOSÉ DANILO DE MELO NERI, qualificado nos autos. Com o trânsito em julgado, defiro o levantamento, pelo réu, dos valores apreendidos consigo (fl. 14 - R\$ 199,25) e determino a destruição dos entorpecentes, oficiando-se. Oportunamente, feitas as comunicações e anotações de estilo, arquivem-se. Registre-se. Intimem-se". Após lida a sentença, o Ministério Público, a Defesa e o(a) ré(u) manifestaram interesse em não recorrer. Saem os presentes cientes. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário).

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 17 de abril de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.